

1501710-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Flávio, este faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, senão vejamos: 2. Reconhecimento da incidência do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Tráfico privilegiado. Verifica-se plenamente possível, no caso em lume, a diminuição da pena nos termos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Isso porque, Flávio é primário, com bons antecedentes e não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:1501710-10.2022.8.26.0228 - C. 2022/000244 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501710-10.2022.8.26.0228 - C. 2022/000244

Réu:

FLÁVIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR

Aos 08 de agosto de 2022, às 14:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Aberta, com as formalidades legais, observou-se no lobby da sala virtual, tendo se verificado a exitosa conexão da representante do Ministério Público, na pessoa da Dra. CLÁUDIA PORRO, presente o réu FLÁVIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do Dr. MATHEUS SILVEIRA PUPO, OAB/SP 258.240, ausente a testemunha de Defesa Bruno Nunes Petrucci. Abertos os trabalhos, pela Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, o réu interrogado, pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, pela mesma foi dito: FLÁVIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR foi denunciado como incurso no art. 33 "caput", da Lei 11.343/06 porque dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 16h36, na Rua Washington Luis, nº 192, República, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 papелotes de Cocaína (massa líquida 4,6g), 04 comprimidos de Ecstasy - Tenanfetamina (massa líquida 0,9g), 03 unidades de LSD - Lisérgica (massa líquida 0,04g), e 01 papелote de MDMA - Metilenodioximetanfetamina (massa líquida 1,4g), conforme auto de exibição apreensão

a fls. 11/12 e laudo de constatação a fls. 14/18, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico de drogas. Segundo o apurado, após veiculação na imprensa de que motoboys estariam realizando "delivery de drogas", diligências policiais apuraram que um homem realizaria entrega de entorpecentes na região da Praça da República. Então policiais civis deslocaram-se para lá. No local, os agentes públicos viram o denunciado nervoso após notar a presença de policiais, pois ele acelerou o passo para entrar em um prédio, e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram 04 comprimidos de "ecstasy", 03 porções de "LSD", 02 papérolas de cocaína e 01 papérola de MDMA; ainda, foi apreendida 01 maquininha de pagamento com cartão de crédito/debito, marca "Ton", e 01 papel com anotações de um possível pedido. Indagado, ele confessou que realizava venda e entrega de drogas aos clientes que pediam via um aplicativo de relacionamento. O denunciado foi conduzido ao distrito policial e preso em flagrante. Interrogado, optou por silenciar. As circunstâncias que envolveram a conduta do indiciado, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como a máquina de cartão e anotação de pagamento, evidenciam a prática do tráfico de drogas. Devidamente citado, apresentou resposta escrita. Ao longo da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, procedendo-se ao interrogatório. É o breve relato. A presente ação penal PROCEDE. A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e notadamente pelo laudo de exame químico toxicológico a fls. 95/98 juntado aos autos. Não restam dúvidas, outrossim, quanto a autoria. O réu na fase policial ficou em silêncio. Perante o Juízo, o réu confessou a prática do delito. Não tem envolvimento com organização criminosa. Praticou o delito porque ficou desempregado em razão da pandemia. Era usuário de drogas e amigos pediam drogas. Hoje trabalha em loja e está arrependido. Tal confissão restou corroborada pelas demais provas coligidas e em especial pela palavra dos Policiais Bruno Diego de Souza Bassan e Claudio Severino Boscolo. Ante todo o exposto aguarda-se seja a presente ação penal julgada inteiramente PROCEDENTE, CONDENANDO-SE o réu nos exatos termos da denúncia.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, pelo mesmo foi dito: Flávio Brito dos Santos Júnior, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que lhe move a Justiça Pública, vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, por seus advogados abaixo firmados, com fulcro no art. 404, parágrafo único c.c. art. 394, § 5º do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais, conforme passa a expor: 1. Síntese dos Fatos. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 (fls. 82/85). Conforme se depreende da peça acusatória, ao realizarem diligências na região da Praça da República, os Policiais Civis Bruno Diego de Souza Bassan e Claudio Severino Boscolo abordaram Flávio, após acreditarem que este apertou o passo e demonstrou nervosismo quando os notou no local. Sendo assim, em revista pessoal, foram localizadas apenas 4,6g de cocaína; 0,9g de Tenanfetamina (MDA); 0,04g de LSD; e 1,4g de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), assim como uma máquina para pagamento em cartão (fl. 97/98 e 120/122), tendo sido realizada a prisão em flagrante. Em seu interrogatório na Delegacia, Flávio optou por exercer seu direito constitucional de manter-se em silêncio (fl. 05). Posteriormente, foi concedida a liberdade provisória (fls. 52/54), uma vez que o acusado é primário, possui residência fixa e a quantidade de drogas é mínima. Frisou-se, ainda, que, no momento oportuno, poderá ser reconhecido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (fl. 53:)

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fl. 87/88), designada audiência para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa no dia 05 de abril de 2022. Apresentada Resposta à Acusação, optando a defesa por se manifestar em alegações finais, além de arrolar a testemunha, Bruno Nunes Petrucci (fls. 110/111); foi confirmado o recebimento da exordial acusatória (fl. 123), determinando-se que esta defesa informasse os dados da referida testemunha para sua participação remota em audiência, uma vez que reside em Araras/SP. No entanto, tal decisão foi publicada no mesmo dia da audiência marcada anteriormente, de forma que não houve tempo hábil para a coleta de tais dados: Enfim, a audiência foi realizada em 05 de abril do corrente ano, ouvindo-se apenas

os Policiais Civis mencionados. Posteriormente, em audiência de continuação, realizada no dia 08 de agosto de 2022, houve o interrogatório de Flávio - sem a oitiva da testemunha de defesa, que não foi localizada -, assim como concessão de prazo para apresentação de alegações finais orais. Pois bem, como já reconhecido pelo próprio juízo ao conceder a liberdade provisória em favor de Flávio, este faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, senão vejamos: 2. Reconhecimento da incidência do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Tráfico privilegiado. Verifica-se plenamente possível, no caso em lume, a diminuição da pena nos termos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Isso porque, Flávio é primário, com bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Explica-se: Sua primariedade se comprova através da certidão de antecedentes criminais (fls. 36/37). Além disso, em sua confissão em juízo, o acusado reconheceu que a traficância foi um ato isolado em sua vida. De outro lado, inexistente nos autos qualquer prova no sentido de que Flávio "se dedique às atividades criminosas" ou "integre organização criminosa". Na mesma esteira, os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado - única prova acusatória produzida no contraditório judicial - não trouxeram nenhuma indicação no sentido de que este integrasse organização criminosa. Nesse sentido, deve-se "militar em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa." (STF, HC n. 199.912. Rel. Gilmar Mendes, j. 05/04/2021). Ainda, destaca-se que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas não representam óbice para o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores: "Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada." (STF, HC 193.223 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe em 11.12. 2020) (grifos nossos). "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elege-se dois elementos específicos - necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas - para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 4. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 5. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. 6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 7. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 8. Apenas

circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base. 9. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se única e exclusivamente na natureza ou quantidade de droga apreendida; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com considerações exclusivamente acerca daqueles vetores. 10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 609.219/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/09/2021). E mesmo se representassem, este próprio juízo, como já mencionado, reconheceu que a quantidade de drogas é mínima, e que era perfeitamente possível a concessão do Tráfico Privilegiado (fl. 53). Portanto, preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, requer-se a aplicação da causa de diminuição da pena em favor do acusado. Ademais, tendo em vista que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal são integralmente favoráveis ao réu, como sua primariedade e confissão espontânea, roga-se pela incidência da diminuição da pena em seu patamar máximo, qual seja, 2/3. Consequentemente, tendo em vista que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, nos termos da jurisprudência do STF (HC 118.533, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia), roga-se pela conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; ou, pelo menos, pela fixação do regime aberto para o cumprimento da sanção (HC n. 596.630, Min. Rogério Schietti Cruz, j. 8/9/2020). Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite ad argumentandum tantum, requer-se a fixação da pena no patamar mínimo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, fixando-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 3. Pedidos. Ante o exposto, requer seja reconhecida a incidência do art. 33, §4º da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), reduzindo-se a pena em seu patamar máximo (2/3); bem como fixando a conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteia-se pela fixação da pena de Flávio no patamar mínimo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, determinando-se o regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. Termos em que pede deferimento. São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. FLÁVIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 16h36, na Rua Washington Luis, nº 192, República, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 papелotes de Cocaína (massa líquida 4,6g), 04 comprimidos de Ecstasy - Tenanfetamina (massa líquida 0,9g), 03 unidades de LSD - Lisérgida (massa líquida 0,04g), e 01 papелote de MDMAMetilenodioximetanfetamina (massa líquida 1,4g), conforme auto de exibição apreensão a fls. 11/12 e laudo de constatação a fls. 14/18, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico de drogas. entorpecentes na região da Praça da República. Então policiais civis deslocaram-se para lá. No local, os agentes públicos viram o denunciado nervoso após notar a presença de policiais, pois ele acelerou o passo para entrar em um prédio, e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram 04 comprimidos de "ecstasy", 03 porções de "LSD", 02 papелotes de cocaína e 01 papелote de MDMA; ainda, foi apreendida 01 maquininha de pagamento com cartão de credito/debito, marca "Ton", e 01 papel com anotações de um possível pedido. Indagado, ele confessou que realizava venda e entrega de drogas aos clientes que pediam via um aplicativo de relacionamento. O denunciado foi conduzido ao distrito policial e preso em flagrante. Interrogado, optou por silenciar. As circunstâncias que envolveram a conduta do indiciado, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como a máquina de cartão e anotação de pagamento, evidenciam a prática do tráfico de drogas. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação, ao final interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos em que denunciado o réu. A Defesa, por seu turno, pugnou

pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, em caso diverso, que acolhidas as demais teses. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. Com efeito, não bastasse preso em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata do crime, também confesso em juízo. Por sua vez, igualmente em juízo, sob o crivo do contraditório, não só reconhecido pelos policiais civis diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante, como em tudo confirmada a acusação tal como lançada na denúncia. Consigne-se que a conduta afinal demonstrada, em tudo se amolda ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. É o quanto basta à condenação firme e segura do réu. Quanto aos depoimentos dos policiais civis em ambas as fases, não há porque desacreditá-los justamente por serem policiais. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais o acusado, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado. Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelo réu, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminoso, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito. Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no BO de fls. 7/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, anotação de fls. 13, laudo de constatação de fls. 14/18, laudos de fls. 118/119, 120/122, e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 106/109, com resultado positivo para as substâncias entorpecentes cocaína, tenanfetamina (MDA), lisérgica (LSD), e metilenodioximetanfetamina (MDMA). Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 83/85, para condenar o réu FLAVIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à primariedade e ausência de antecedentes de vulto (fls. 34/35), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, também considerada numa segunda fase a expressa confissão, revelando verdadeiro arrependimento, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal. Com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, sendo primário e não ostentando antecedentes criminais de relevância, reduzo a pena base acima fixada de 2/3, tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal. Primário, sem antecedentes de peso, não se configurando tráfico de expressão, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta. Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, tal como regulamentada pelo juízo das execuções criminais, e mais dez (10) dias-multa, totalizando pois 176 dias-multa, no mínimo legal. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Neste ato, sem recurso das partes e réu, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se guia de recolhimento e ofícios de estilo, arquivando-se. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas em nuvem pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjsp_jus_br/

EgEY8KHRdSZHgm3JNLi4Nw8B_VQp0MrHv3HXy5jqDvCUDw?e=0rvlGR